

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077399-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: HAMILTON DISNEY DA SILVA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ARTROPLASTIA DE QUADRIL À DIREITA. LAUDO MÉDICO NÃO ATESTA A NECESSIDADE URGENTE DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGO 196 E 198 DA CRFB/88 E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERDIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER dos recurso e NEGAR-LHE provimento, para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5077399-11.2024.4.02.5101

510014802473 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077399-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: HAMILTON DISNEY DA SILVA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta pela parte autora, a fim determinar aos réus que providenciem a cirurgia necessaria ARTROPLASTIA DE QUADRIL À DIREITA, em até 72 (setenta e duas) horas, diante do indeferimento da tutela antecipada neste sentido pelo Juízo a quo.

Sustenta a parte autora que fora submetido à cirurgia de quadril (artroplastia total de quadril à direita) em novembro de 2018 no Hospital Municipal Barata Ribeir. Contudo, sendo posteriormente inserido na fila de cirurgia do INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - INTO para a realização de artroplastia de quadro à esquerda devido ao surgimento de dor local, sendo constatado irregularidades nas inserções musculares nas cristas ilíacas e tuberosidades isquiáticas, notadamente na crise ilíaca direita, além de irregularidades adjacentes no ilíaco e ossos adjacentes, e heterogeneidade do fêmur. No momento, apresenta intensa dor em quadril, tendo que fazer uso contínuo de analgésicos com opióide, o que prejudica sua deambulação e a realização de atividades cotidianas.

Contrarrazões foram apresentadas em evento 21.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

I- DO DIREITO À SAÚDE

Inicialmente, o direito à saúde dentro do rol de direitos humanos, foi reconhecido mundialmente, por meio da Declaração Universal dos Direitos humanos de 1948, que em seu artigo XXV garantia a toda pessoa o direito a um padrão de vida que fosse capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar.

Não obstante existirem previsões constitucionais anteriores a 1988 sobre saúde pública, eram destinadas apenas aos socorros públicos emergenciais. Somente com a Constituição de 1988 foi institucionalizado, de fato, o direito à saúde como um direito fundamental, conforme previsão em seu artigo 6º, dentro do rol dos direitos sociais, sem qualquer cunho prestracional por parte do cidadão, sendo gratuito e universal.

Assim, o direito à saúde, como um direito fundamental de segunda geração, requer atuação positiva do Estado, no desenvolvimento de políticas públicas e prestação deste serviço público de saúde, sendo suas diretrizes previstas especificamente nos artigos 196 a 200, que, sobretudo, atribuem ao Poder Público o dever de assegurar/concretizar tais direitos.

Posteriormente, o atual SUS foi regulamentado pela Lei nº 8.080/90, que detalha o funcionamento do sistema e instituiu os preceitos e seus objetivos. com aprovação da Emenda Constitucional 29, o SUS passa a ser administrado de forma tripartite e conta com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os gestores são responsáveis pela administração dos recursos, sua implantação e qualidade. Atualmente, o orçamento do Governo Federal repassado para o Ministério da Saúde gira em torno 101 bilhões de reais.

Contudo, não basta sua mera positivação, sendo necessário efetivar o direito fundamental da saúde, considerando-se os pilares de um Estado Social e Democrático de Direito, onde a dignidade humana deve ser garantida.

Vale ressaltar que o STF tem icônicos julgados tratando do direito à saúde. Em célebre julgamento no STF, o Ministro Celso de Mello ao julgar caso de paciente com HIV que dependia de medicamentos do SUS assegurou que o direito à saúde representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde - além de qualificar se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 271286. RS, Relator: Celso de Mello. Data de Julgamento: 11/09/2000, Segunda Turma. Acesso em 20/02/2013.)

Neste sentido é também o entendimento da Desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria do TRF4 ao ratificar que o direito fundamental à saúde encontra-se garantido na Constituição, descabendo as alegações de mera norma programática, de forma a não lhe dar eficácia. Para a desembargadora quando confrontada com este direito ela observa determinados pressupostos básicos, quais sejam:

a) eventual concessão da liminar não pode causar danos e prejuízos relevantes ao funcionamento do serviço público de saúde;

b) o direito de um paciente individualmente não pode, a priori, prevalecer sobre o direito de outros cidadãos igualmente tutelados pelo direito à saúde;

c) o direito à saúde não pode ser reconhecido apenas pela via estreita do fornecimento de medicamentos;

II- DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.

O art. 196, da CF/88, norma de aplicabilidade plena, declara o direito à saúde: *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."*

Assim, ainda que as ações e serviços públicos de saúde sejam informados pela descentralização, conforme a norma constitucional inscrita no art. 198, I, da CRFB (e repetida no art. 7º, IX, da Lei n.º 8.080/1990), certo é que a própria Carta Magna estabelece uma

competência concorrente (art. 24, XII) entre os entes constitutivos da federação para legislar sobre o assunto, bem como a competência material comum aos mesmos para realizar as ações correspondentes.

Tanto assim que a Lei n.º 8.080/1990 discrimina as competências da União Federal em seu artigo 16. Acrescente-se que, no que toca ao financiamento dos serviços de saúde, a União Federal tem participação direta, ainda que os serviços sejam prestados prioritariamente pelos Estados e Municípios.

A Portaria nº 3.916/MS/GM, de 30 de outubro de 1998 prevê a RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, de responsabilidade do Ministério da Saúde e prevê, igualmente, a gestão do SUS pelos três níveis de governo, de modo a se promover um fornecimento de remédios racionalizado, padronizado e eficiente.

Desse modo, não é possível o argumento de que a Constituição ou mesmo sua lei integradora tenham querido limitar o acesso à rede pública de saúde ou às ações de saúde. A melhor interpretação é justamente a contrária. Deve ser amplo o atendimento, independentemente da correspondência federativa da entidade pública procurada ou das atribuições administrativas de cada ente político.

Assim, a divisão de responsabilidades entre União, Estado e Município não pode vincular a atuação do SUS frente ao administrado, que depende do Poder Público para garantir o seu direito à saúde.

Por outro lado, a solidariedade no campo assistencial do SUS sempre proporcionará ao ente obrigado judicialmente ao desembolso de valores, a possibilidade de ressarcimento ou compensação administrativa junto aos demais. As ações do SUS dependem de uma atuação coordenada dos entes públicos envolvidos na sua organização.

No que toca ao fornecimento de remédios, a União Federal tem responsabilidade sobre o Financiamento da Assistência Farmacêutica Básica, nos termos da Portaria nº 2.084/GM de 26 de outubro de 2005, repassando para os Estados e Municípios a verba para a compra dos medicamentos para a Atenção Básica.

Logo, a União tem competência não só para traçar regras gerais a serem cumpridas no SUS, como também para promover, quando necessário, a devida assistência em concreto. Os mecanismos de compensação dos entes que atuam no SUS - União, Estados e Municípios - não podem impedir a prestação positiva do Estado. No mesmo sentido, dispõe o Enunciado 43 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

Enunciado 43: "A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS."

Neste sentido, confira-se recente jurisprudência do STF, que ratifica seu posicionamento acerca da solidariedade dos entes públicos no fornecimento de medicamentos, nos seguintes termos:

DECISÃO: Vistos. União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Espírito Santo, que manteve a decisão do juízo monocrático, que indeferiu o chamamento da União para integrar o polo passivo de demanda em que se discute fornecimento de medicamentos. Opostos embargos de declaração (fls. 219/220), foram rejeitados (fls. 223/224). Alega o recorrente violação dos artigos 37, caput, e 198, inciso I, da Constituição Federal. Contrarrazoado (fls. 241 a 247), o recurso extraordinário (fls. 229 a 230) foi admitido (fl. 249). Decido. Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá "quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão". Não merece prosperar a irresignação. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre legitimidade passiva da União em ação em que se discute a obrigação de fornecer medicamentos, em harmonia com a jurisprudência desta Corte que, no julgamento do RE nº 808.059/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJ de 1º/2/11), fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária. Nesse sentido, também, as recentes decisões monocráticas: AI nº 817.241/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14/10/10; RE nº 839.594/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 3/3/11, e AI nº 732.582/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 17/3/11. Sobre o tema, ainda, anote-se o seguinte precedente: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTETÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação

dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido" (RE nº 607.381/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 17/6/11) Diga-se, por fim, que nos autos do RE nº 566.471, Relator o Ministro Marco Aurélio, discute-se a possibilidade de condenação de Estados ou municípios ao custeio de medicamentos que não integram a lista daqueles fornecidos gratuitamente pelo sistema de saúde pública. Essa matéria, portanto, não se confunde com a do presente recurso extraordinário, que trata do chamamento da União ao processo e da eventual responsabilidade solidária dos entes da Federação. Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se (STF, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, RE 668603 / ES, data da julgamento: 26/04/2013).

III- DO CASO CONCRETO

Nos autos principais, o NAT esclarece que, acordo com documentos médicos acostados ao processo (Evento 1, ANEXO3, Páginas 10 e 11 dos autos originários), o Autor está sendo assistido neste momento por uma unidade de saúde pertencente ao SUS e habilitada na Rede de Traumatologia e Ortopedia de Média e Alta Complexidade no Estado do Rio de Janeiro, a saber, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO. Assim, informa-se que é de sua responsabilidade garantir a continuidade do tratamento ortopédico do Autor ou, caso não possa absorver a demanda, deverá encaminhá-lo a uma unidade apta em atendê-lo. Em consulta à plataforma online do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO (ANEXO II), foi observado que o Autor se encontra em fila para realização de cirurgia de (revisão) não INTO (sem enxerto ósseo), posição: 201º, situação: aguardando chamado.

Convém observar que o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia é unidade pertencente à Rede de Traumatologia e Ortopedia de Média e Alta Complexidade no Estado do Rio de Janeiro e, assim, *"entende-se que a via administrativa para o caso em tela já foi utilizada e que tal unidade é responsável por garantir o tratamento ortopédico do autor ou, caso não possa absorver a demanda, deverá encaminhar o Autor a uma unidade apta em atendê-lo"*.

Por fim, assevera-se que foi solicitada urgência no tratamento cirúrgico do demandante. Com efeito, conclui-se que *"a demora exacerbada na realização da cirurgia poderá influenciar negativamente no prognóstico em questão"*.

Não obstante se tratar de direito à saúde de insuma importância à vida da parte autora, há 201 pessoas na fila antes do autor, ora recorrente. Diante disso, não se afigura razoável impor aos recorridos que seja imediatamente marcada a cirurgia, em detrimento dos demais pacientes que precedem na fila, e cujo estado de saúde é desconhecido nos autos, podendo inclusive ser mais graves que o da autora.

Com efeito, em que pese a alegação de que a demora na realização da cirurgia possa comprometer o prognóstico em questão, com a dificuldade de deambular, não há elementos que justifiquem o desrespeito na ordem cronológica da fila, tal como risco de morte ou necrose de tecidos ou risco de perda definitiva de movimento.

De fato, o quadro do autor requer repouso, ministração de medicação para alívio da dor, até que seja realizado o procedimento que realmente seja efetivo ao quadro, visto que o autor informa que já fora operado anteriormente, tendo piorado seu estado de saúde. Conforme a instrução dos autos e verificação de perícia médica, pode até mesmo ser concluído outro tratamento menos agressivo ao autor, para recuperar seus movimentos na íntegra.

Embora seja uma opção para casos mais avançados, existem diversas outras abordagens terapêuticas que podem ser eficazes em diferentes estágios da doença. O tratamento da coxartrose geralmente começa com medidas conservadoras, que incluem analgésicos, anti-inflamatórios e outros medicamentos podem ajudar a aliviar a dor e reduzir a inflamação; fisioterapia, com exercícios específicos podem fortalecer os músculos ao redor do quadril, melhorar a flexibilidade e aumentar a amplitude de movimento; perda de peso para aliviar a pressão sobre a articulação do quadril e diminuir a dor; aparelhos ortopédicos tais como andadores, bengalas e outros dispositivos podem auxiliar na locomoção e reduzir o impacto sobre a articulação e injeções de corticosteroides ou ácido hialurônico podem proporcionar alívio da dor a curto prazo.

Assim, a cirurgia é indicada quando os tratamentos conservadores não são mais eficazes em controlar a dor e a incapacidade.

É certo que a parte é titular do direito constitucional à saúde (arts. 6º e 196 da Constituição da República), e que, como tal, pode exigir a prestação desse serviço público essencial por parte do Estado. Contudo, não se pode ignorar que o princípio da isonomia também tem assento constitucional (art. 5º, *caput*), e, em assim sendo, há igualmente de ser sopesado em casos tais como o que ora se analisa. Deve-se relembrar, sobretudo, que “*assim como jamais se interpreta um texto normativo, mas sim o direito, não se interpretam textos normativos constitucionais isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços*” (GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 166).

Com efeito, não se pode simplesmente tratar do assunto mediante subsunção mecânica do quadro fático da parte autora ao direito constitucional à saúde, devendo-se ainda levar em consideração o papel que desempenha, no presente caso, o princípio da isonomia.

Assim, permitir ao demandante que obtenha pronto atendimento na realização da cirurgia pretendida, em detrimento de outros pacientes que também estão acometidos de graves enfermidades de similar natureza e que aguardam pacientemente na fila de espera, implicaria não no reconhecimento de um *direito*, mas sim na geração de um *privilegio*, o que está vedado em nosso ordenamento jurídico.

In casu, portanto, não vejo qualquer violação de direitos fundamentais, nem conduta ilegal ou abusiva do Poder Público que justifique a atuação do Poder Judiciário, mesmo porque **não há nos autos comprovação de iminente risco de morte** que justifique, excepcionalmente, a quebra do procedimento organizacional adotado na esfera administrativa.

A jurisprudência não tem tratado casos análogos de modo diferente:

AGRAVO INTERNO. LIMINAR. CIRURGIA. FILA. ORDEM DE INSCRIÇÃO. OBEDIÊNCIA. ISONOMIA. 1. A despeito da generosa interpretação dada ao art. 196 da Constituição por alguns arestos, certo é que o Estado não tem condições de assegurar, a todos e de pronto, ‘o acesso ao tratamento necessário a cura de suas doenças’, principalmente nos poucos hospitais públicos de referência existentes no País. 2. Sem demonstração de ilegitimidade da fila e, pois, da ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXIX, CF), qualquer decisão judicial que determine cirurgia imediata caracterizaria injustificada vantagem pessoal a vista da situação comum em que se encontram os vários pacientes na fila, eis que “descabe ao Judiciário estabelecer prioridades de natureza médica. Este não é administrador do SUS e, caso se admitisse a sua intervenção indevida, teria também que resolver os problemas decorrentes de sua atuação, haja vista que se uma pessoa realiza o exame por força de tutela judicial, outra, que teria direito por ordem natural, seria prejudicada” (cf. TRF2, 7ª Turma Esp., AI no 2010.02.01.017554-5, Rel. Des. Fed. Jose Antonio Lisboa Neiva). 3. Assim, embora lamentando profundamente a situação, não cabe ao Judiciário quebrar a isonomia. 4. Agravo interno desprovido (TRF-2, AI 217227, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, j. 10/10/2012).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ISONOMIA. RESPEITO À FILA ADMINISTRATIVAMENTE ORGANIZADA. 1. O direito à saúde implica para o Poder Público o dever inescusável de adotar providências necessárias e indispensáveis para a sua promoção, estabelecidas de forma universal e igualitária. Nesse contexto jurídico, se o Poder Público negligencia no atendimento de seu dever, cumpre ao Poder Judiciário intervir, num verdadeiro controle judicial de política pública, para conferir efetividade ao correspondente preceito constitucional. 2. Todavia, o acesso ao referido direito deve ser compatibilizado com o princípio da isonomia, de forma a não garantir privilégios àqueles que procuram o Judiciário em detrimento dos que aguardam por tratamentos e cirurgias de acordo com a fila administrativamente estabelecida. Assim, não cabe ao Judiciário administrar hospitais, estabelecendo prioridades de natureza médica. Precedentes. 3. Dessa forma, cabe à Administração Pública, mediante exame com base em critérios técnicos, aferir a possibilidade de internação no INCA ou em qualquer outro hospital da rede pública, respeitando a fila administrativamente estabelecida. 4. Por outro lado, é inviável, em um quadro insatisfatório, socializar o custeio de internação em rede hospitalar privada. Do mais, o deferimento do pedido, nesta hipótese, também representaria verdadeira preterição aos pacientes que aguardam na fila de espera. 5. Embargos infringentes conhecidos e providos. (EAC 201151014901233 Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA TERCEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA - DJF2R - Data::02/10/2012 - Página::28/29)

CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA DE CATARATA. LIMINAR SATISFATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FILA DE ESPERA. ORDEM DE INSCRIÇÃO. 1. Não se conhece do agravo retido interposto pela União, porquanto sua apreciação não foi requerida em apelação (art. 523, § 1º, do CPC). 2. Conquanto extinto o processo sem resolução do mérito, verifica-se que, em verdade, à Fazenda Pública foi imposta a obrigação de prestar atendimento médico à autora, por força da antecipação de tutela deferida. Logo, impõe-se o reexame da demanda pelo Tribunal (art. 475, I, do CPC), razão por que se considera realizada a remessa necessária. Ademais, importa apreciar o mérito da causa, porquanto, embora satisfativa e irreversível, a decisão liminar, provisória por natureza, não pode se sobrepor à sentença, que constitui o provimento jurisdicional definitivo (art. 273, § 5º, do CPC). 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela União, vez que lhe cabe a administração do Hospital de Bonsucesso, nosocômio onde a demandante está cadastrada para a realização do procedimento cirúrgico ora postulado. 4. A despeito da generosa interpretação dada ao art. 196 da Constituição

por alguns arrestos, certo é que o Estado não tem condições de assegurar, a todos e de pronto, 'o acesso ao tratamento necessário à cura de suas doenças'. 5. Sem demonstração de ilegitimidade da fila e, pois, da ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXIX, CF), qualquer decisão judicial que determine cirurgia imediata caracterizaria injustificada vantagem pessoal à vista da situação comum em que se encontram os vários pacientes na fila, eis que descabe ao Judiciário estabelecer prioridades de natureza médica. Este não é administrador do SUS e, caso se admitisse a sua intervenção indevida, teria também que resolver os problemas decorrentes de sua atuação, haja vista que se uma pessoa realiza o exame por força de tutela judicial, outra, que teria direito por ordem natural, seria prejudicada- (cf. TRF2, 7ª Turma Esp., AI nº 2010.02.01.017554-5, Rel. Des. Fed. José Antônio Lisboa Neiva). 6. Agravo retido não conhecido, remessa necessária e apelação providas. (APELRE 201151010145031 Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA E-DJF2R - Data::06/09/2012 - Página::449)

No mesmo sentido, cito julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. FILA DE ESPERA. SEPARAÇÃO DE PODERES E ISONOMIA. A organização da fila de espera para prestação de serviços de saúde é incumbência da Administração Pública, e ao Judiciário só é dado corrigir ilegalidades. Dessa forma, acatar o pleito da autora, para que ela seja submetida a certa cirurgia ortopédica, à frente de outros da fila e quando as informações mostram que ela faltou à consulta marcada, é cultuar o clientelismo e afrontar a organização administrativa. Se há fila e critério, e não se questionam os critérios, apenas se mostra aceitável a intervenção jurisdicional para impor a observância da correta ordem, em respeito ao tratamento isonômico que deve ser dado aos necessitados, mas nunca para homenagear o casuísmo e o seu irmão siamês, o populismo judicial. Não pode o Judiciário priorizar um paciente em detrimento de outro apenas com argumentos genéricos, sem considerar as prioridades, as enfermidades e a ordem administrativa em prol daqueles que também aguardam para iniciar ou dar continuidade a tratamento. Se há qualquer desvio, ele deve ser indicado e punido. Apelo desprovido. No contexto observado, deve-se reconhecer que a pretensão recursal se encontra prejudicada. Ante o exposto, com base no art. 557 do CPC, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intime-se. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.397.495 - RJ 2013/0261667-0, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 23/09/2013).

Sobretudo, havendo outros pacientes em igual ou mais crítica situação clínica do que a da parte autora, nesta mesma fila de espera e em posição anterior àquela que a mesma ocupa, não se afigura isonômico que, em virtude de ordem judicial, o autor seja submetido de pronto à cirurgia de que necessita, a despeito dos outros pacientes, que, tanto quanto ele, são titulares do direito constitucional da assistência à saúde, fornecida pelo Estado.

Sendo assim, não havendo prova de risco iminente de perda da vida ou de movimentos ou membros do corpo, não há como o Judiciário se sobrepor às funções administrativas do Executivo na gestão do sistema público de saúde. Deve ser respeitada a fila de espera, inclusive, em respeito à isonomia perante os demais pacientes, devendo ser mantido o indeferimento da tutela.

Portanto, ainda que esta relatora se veja muito sensibilizada com a situação sofrida pela parte autora, determinar uma cirurgia neste momento, sem a devida instrução probatória, poderia por em risco, mais um vez, o sucesso do tratamento da parte autora, visto que a mesma informa que já fora operada e que seu quadro agravou, além do tratamento desigual com os demais cidadãos que aguardam a fila de espera da cirurgia, razão pela qual, ao menos neste momento, não vislumbro elementos para deferimento da medida.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** dos recurso e **NEGAR-LHE** provimento, para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de **urgência**. Sem custas, nem honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.